

刑法  
No86

## 共通問題 R3-17

(配点：3)

月 日

月 日

正当防衛（刑法第36条第1項）に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい。

1. 刑法第36条第1項における「急迫」というには、法益の侵害が現に存在していることを要する。
2. 刑法第36条第1項における「やむを得ずにした行為」というには、反撃行為が権利を防衛する手段として必要最小限度のものであること、すなわち侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであることを要する。
3. 急迫不正の侵害がないのにあると誤信して、防衛の意思で反撃行為を行った場合でも、正当防衛が成立し得る。
4. 刑法第36条第1項にいう「権利」は、個人的法益に限られ、国家的・社会的法益は、これに含まれない。
5. 刑法第36条第1項における「不正の侵害」というには、可罰的な行為であることを要しない。

|         |             |     |
|---------|-------------|-----|
| No.86   | 正当防衛        | 正答率 |
| 共通R3-17 | 正解 2、5（順不同） | 87% |

### 1 誤っている

最判昭 46.11.16。判例は、36条1項にいう「急迫」とは、法益の侵害が現に存在しているか、又は間近に押し迫っていることをいうとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、そのような状況が存在した場合、公的機関による保護を求める余裕がなく、侵害の脅威にさらされた法益を保護するためには、実力を行使することが必要となるということを挙げている。よって、「急迫」というには、必ずしも法益の侵害が現に存在していることを要するわけではない。したがって、本記述は、36条1項における「急迫」というには、法益の侵害が現に存在していることを要するとしている点で、誤っている。

### 2 正しい

最判昭 44.12.4。判例は、左手の中指と薬指をつかんで逆にねじあげられたのに対して、胸の辺りを1回強く突き飛ばし、治療45日を要する頭部打撲症の傷害を負わせたという事案において、36条1項の「やむを得ずにした行為」とは、「急迫不正の侵害に対する反撃行為が、自己または他人の権利を防衛する手段として必要最小限度のものであること、すなわち反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであることを意味するのであつて、反撃行為が右の限度を超えず、したがって侵害に対する防衛手段として相当性を有する以上、その反撃行為により生じた結果がたまたま侵害されようとした法益より大であつても、その反撃行為が正当防衛行為でなくなるものではない」としている。したがって、本記述は正しい。

### 3 誤っている

正当防衛（36条1項）が成立するためには「急迫不正の侵害」の要件が必要であるから、急迫不正の侵害がない場合、正当防衛は成立し得ない。なお、本記述のような場合について、下級審判例には、誤想防衛として故意が阻却されたとしたものがある（広島高判昭 35.6.9）。したがって、本記述は、急迫不正の侵害がないのにであると誤信して、防衛の意思で反撃行為を行った場合でも、正当防衛が成立し得るとしている点で、誤っている。

### 4 誤っている

最判昭 24.8.18。判例は、国家的・社会的法益などの公共的法益についても正当防衛が許されるべき場合があるが、それは国家公共の機関の有効な公的活動を期待しえない極めて緊迫した場合においてのみ例外的に許容されるべきものとしている。よって、36条1項にいう「権利」は個人的法益に限られず、国家的・社会的法益も含まれ得る。したがって、本記述は、36条1項にいう「権利」は、個人的法益に限られ、国家的・社会的法益は、これに含まれないとしている点で、誤っている。

### 5 正しい

大判昭 8.9.27。判例は、36条1項の「不正」とは違法であることを意味するとしているが、可罰的違法性までは要求するものとは解されていない。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、不正の侵害は正当防衛を可能にするための前提要件であり、侵害者を処罰するためのものではないということを挙げている。よって、「不正の侵害」というには、可罰的な行為であることを要しない。したがって、本記述は正しい。

以上より、正しい記述は2と5であり、したがって、正解は肢2と肢5（順不同）となる。